

1524495-97.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/03/2022

... a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524495-97.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524495-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WAGNER GONÇALVES DE JESUS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

YANKA APARECIDA MIRANDA e WAGNER GONÇALVES DE JESUS, qualificados nos autos foram denunciados como incurso nos art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV combinado com o artigo 14, inciso II e art. 329, caput na forma do artigo 69 todos do Código Penal. Segundo o apurado, no dia 09 de outubro de 2021, por volta de 04h50 horas, na Rua Lagoa Formosa, 217, Vila Matilde, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e também com um terceiro indivíduo não identificado, durante o repouso noturno, tentaram subtrair em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo coisas alheias móveis do interior da residência, pertencentes a vítima D.A.P., não consumando o crime devido a circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

É dos autos, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, YANKA APARECIDA MIRANDA e WAGNER GONÇALVES DE JESUS, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com um terceiro indivíduo desconhecido, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, acelerando o veículo VW/GOL, placas KLA3164 em direção aos policiais para fugir da abordagem.

Recebida a denúncia os réus foram citados, notificados e apresentaram resposta à acusação (fls. 224/226 e 227/232).

A proprietária do aparelho celular apreendido com o corréu Wagner requereu sua restituição e juntou aos autos os documentos de fls. 234/235.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (fls. 240).

Após a manutenção do recebimento da denúncia para ambos os réus, considerando que a ré Yanka preenchia os requisitos legais para ser beneficiada com o acordo de não persecução penal, o Ministério Público ofertou o benefício a ela, que foi aceito e homologado, consoante termo de fls. 253/254.

Quanto ao corréu Wagner prosseguiu-se a audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidos a vítima do furto, os dois policiais e o réu Wagner foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público pugnou pela condenação do réu Wagner nos termos da denúncia.(fls. 296/304).

Já a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, no que toca aos dois delitos que lhe foram imputados.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente absolvição do acusado com relação ao crime de furto, afirmando a Defesa, em suma, que o réu não foi impedido de consumir o delito de furto, mas sim dele desistiu sem ter praticado qualquer ato típico. Em caso de eventual condenação buscou então, a fixação da pena base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e o regime aberto, para eventual cumprimento da pena, o reconhecimento da confissão, a aplicação da "detratação penal", considerando o tempo em que o réu está encarcerado e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Assim vejamos:

O próprio réu, ao ser interrogado em juízo, confessou que tentou furtar a residência da vítima, e realmente arrombou o portão e assim conseguiu entrar. Lá dentro, ouviu Yanka pedindo para ele voltar e ao ouvir um barulho, pensou melhor e resolveu voltar ao veículo. No momento em que estava dando partida em seu automóvel ouviu a policia se aproximando e ao perceber o sinal de parada, realmente acelerou o veículo, pois estava com medo de ser preso. Na fuga, o indivíduo que estava com ele e com sua esposa, abriu repentinamente a porta traseira do carro e pulou para fora do veículo. Dirigiu por mais alguns metros e resolveu parar o carro, ocasião em que foi abordado pela policia. Imediatamente, ao ser abordado, de pronto confirmou que realmente tentou furtar a residência da vítima, mas afirmou que desistiu. Negou ter tentado avançar com o carro contra os policiais, apenas acelerou para fugir, disse que eles vieram por trás e não chegou a ver se havia policiais fora da viatura.

O proprietário da residência, por sua vez, disse que estava fora de sua residência e foi avisado por um conhecido de que havia pessoas no portão tentando entrar em no local. Imediatamente voltou ao local, e visualizou o portão arrombado bem com que a porta da residência também estavam danificadas, mas os rapazes já não estavam mais no local. Em razão disso, ali permaneceu e por volta das 4h da manhã ouviu um barulho de um carro parando em frente a residência e imediatamente acionou a polícia. Viu um rapaz tentando forçar o portão e que dentro do veículo, ainda havia outras pessoas. Assim que a polícia chegou à sua residência os passageiros do veículo empreenderam fuga e tomou conhecimento que após breve perseguição, um casal acabou sendo preso. Afirmou que o rapaz preso, tem as mesmas características do indivíduo que foi por ele visto, tentado arrombar a porta de sua residência, que ainda está danificada.

O policial Wesley, por sua vez, confirmou os fatos narrados na denúncia afirmando que estava em patrulhamento pela região da Vila Matilde e ao receber informação via COPOM, sobre a tentativa de furto a uma residência. Estavam próximos do local e para lá se dirigiram, assim que se aproximaram viram um veículo parado em frente ao número da residência mencionada. Desceram do veículo para tentar uma abordagem, ocasião em que o réu acelerou o veículo em direção aos policiais na tentativa de impedir a prisão. Diante disso, após voltarem à viatura partiram a perseguição e durante o trajeto, um rapaz acabou pulando do veículo e conseguiu fugir e o casal

foi então preso. Não os conhecia antes dos fatos, mas tinha conhecimento de que o veículo por ele utilizados estava sendo utilizado para a prática de furtos no bairro.

Confirmou que parou a viatura atrás do carro do réu, desembarcou para tentar aborda-los, mas foi impedido pelo réu que tentou atropela-los.

No mesmo sentido foram as declarações do policial Patrick que confirmou que estava em patrulhamento com seu parceiro e por volta das 4h da manhã foram informados da ocorrência de um furto a residência. Confirmou ainda, que ambos desceram da viatura para tentar a abordagem mas quase foram atropelados pelo réu, que acelerou a veículo nitidamente na direção dos dois policiais e diante disso, após conseguirem voltar à viatura saíram em perseguição do automóvel gol e o casal acabou sendo preso. Afirmou, ainda, que durante a perseguição, um indivíduo pulou de dentro do veículo em movimento e assim, conseguiu fugir.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas outra solução não há que a condenação do acusado.

Não há que se falar em desistência voluntária no que toca ao delito de furto. Isso porque, o próprio réu afirmou que voltou para o veículo somente após ouvir sua mulher pedindo para que ele desistisse e ainda em razão de ter ouvido barulhos dentro da residência.

Ora, com efeito, para a caracterização da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, necessário se faz que o ato não seja forçado, havendo qualquer tipo de constrangimento seja ele moral ou material à consumação ocorre a tentativa. E foi exatamente isso que ocorreu no caso em tela, já que o acusado voltou para o veículo em razão de pedido de sua esposa, e ainda porque ouviu barulhos no local. Veja-se ademais que segundo a vítima, ela só voltou para sua residência após ser avisada por um conhecido que havia pessoas tentando ali entrar, sendo clara que os furtadores voltaram ao local dos fatos, posteriormente e novamente se puseram a forçar o portão e a porta da moradia para nela ingressar, e que a polícia foi avisada e após perseguição conseguiu prender alguns deles.

Como é cediço, à condenação por furto basta que a declaração da vítima esteja em harmonia com os demais elementos dos autos, que seja confirmada por qualquer outro dado.

Também quanto ao crime de resistência, outra sorte não merece o réu, já que os dois policiais ouvidos em juízo, relataram que após desembarcarem da viatura e se aproximarem do veículo onde estava o réu e seus comparsas, na tentativa de aborda-los, quase foram atropelados pelo acusado que "jogou o veículo para cima dos policiais" fazendo que a abordagem não fosse então realizada naquele momento. Veja-se que somente após embarcarem na viatura e iniciarem uma perseguição ao veículo que era pilotado pelo réu, os policiais conseguiram prender dois dos três furtadores que estavam com o veículo estacionado em frente à residência da vítima, o que confirma que a versão dos dois policiais posto que se não tivesse havido a resistência à prisão no momento da abordagem os três seriam imediatamente presos. É de asseverar, ainda, que o simples fato de a testemunha ouvida ser policial nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu de solicitação de solicitação via COPOM, sem que haja qualquer indício de anterior perseguição pelos policiais houvesse em relação aos acusados, que para espantar

qualquer dúvida a este respeito, nada alegou contra eles.

Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Vale a pena transcrever a ementa do Habeas Corpus nº 74.608-0 em que foi Relator o Eminentíssimo Ministro Celso de Mello, acerca do valor probante dos depoimentos de policiais. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal."

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência."

No que toca à qualificadora do crime de furto, referente ao arrombamento, está veio cabalmente comprovada pelo laudo pericial do local dos fatos, fls. 282/289, conclusivo no sentido de que "a porta que dá acesso a garagem da residência, (...), bem como aquela que dá acesso ao pavimento superior apresentavam sinais de arrombamento, devido a existência de almolgamentos produzidos por instrumento utilizado à guisa de alavanca associada à força muscular aplicado externamente" (fls. 285).

Também o concurso de agentes foi devidamente comprovado nos autos, seja pelos relatos do réu no sentido de que estava na companhia de sua esposa e de um terceiro indivíduo que pulou do carro, no momento em que os policiais os perseguiram, seja ainda pelos depoimentos dos policiais e da vítima, no sentido de que havia várias pessoas, em frente à residência em que os fatos se deram.

De fato, no concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

A tentativa de furto também deve ser reconhecida, na medida o réu e seus comparsas não conseguiram entrar na residência da vítima e assim nada de lá subtraíram.

Caracterizadas, portanto, a infração penal passo a dosimetria da pena:

Do crime de furto qualificado, tentado:

O réu é reincidente, posto que condenado definitivamente pelo crime de tráfico, autos nº 0008288-60.2016.8.26.0006 (fls. 58), o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Além disso, possui outra condenação anterior, (autos nº 0069775-35.2012.8.26.0050), demonstrando que tem personalidade voltada para o crime, fato este que será aqui utilizado para aumentar a pena base em 1/6, nos termos do disposto no art. 59 do Código Penal, perfazendo, 02 anos, 04 meses e 11 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras

circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, presentes duas agravantes, a reincidência acima apontada, bem como a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Veja-se que, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Desse modo, a pena deve ser aumentada em mais 1/5, chegando-se a 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da

conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- “O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.”

O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), “a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda” (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - “(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública” (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

A 9ª Câmara Criminal – Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la".

Por outro lado, não há que se falar em confissão já que ao contrário do alegado pela Defesa, o que acusado afirmou que não praticou a tentativa do furto, posto que desistiu do delito.

Na terceira fase, forçoso se reconhecer a causa de aumento de pena decorrente do "repouso noturno", devidamente comprovado nos autos, e assim sendo a pena deve ser aumentada em mais 1/3, fixando-se o patamar de 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, e 17 dias-multa. Neste ponto, compulsando recentes julgados dos tribunais superiores, verifica-se a necessidade de novas reflexões sobre a questão topográfica nos tipos penais e seus reflexos na dosimetria da pena.

De fato, não se desconhece que há decisões baseadas na mera argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes.

Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis.

Tal entendimento começou, então a mudar notadamente no que diz respeito aos crimes de homicídio e furto, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado- privilegiado", ou mesmo o reconhecimento da figura do "repouso noturno" aos delitos de furtos qualificados.

A doutrina então começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar nestes casos que "a posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação

da pena.

Outras considerações, para não aplicar o aumento do § 1.º às formas qualificadas (§ 4.º ou 5.º), constituem pura política criminal, visando à menor apenação ao acusado, embora distante da técnica de individualização da pena.

Na jurisprudência: STJ: "Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente)" (REsp 940.245-RS, 5.ª T., rel. Félix Fischer, 13.12.2007, v.u.); HC 10.240-RS, 6.ª T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u., DJ 14.02.2000, p. 79.

Em seu voto no HC 306.450-SP, a ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou: Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2.º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1.º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4.º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1.º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico.

Por outro lado, registra-se que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma desta Corte segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento, quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do REsp 842.425/RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2.º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2.º), também não se considera tal ordem para imposição da causa de aumento (§ 1.º).

Em assim sendo, tendo em vista que o furto em tela é qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculos, não há qualquer óbice para aplicação da causa de aumento de pena (art. 155, § 1º, do Código Penal), devendo, portanto ser mantida.

Cumprir destacar julgado que fixa justamente essa orientação ao enfrentar hipótese análoga: PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. BEM AVALIADO EM R\$ 300,00. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA PENA-BASE. SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. ... 3. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus...5. Ordem denegada.

(Processo HC 424098 / SC - Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 06/02/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2018).

No mesmo sentido e corroborando o entendimento ora esposado, o Supremo Tribunal Federal no HC 130952/MG, assim já se pronunciou "HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, C/C O ART. 14, II). CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º) NAS FORMAS QUALIFICADAS DO CRIME DE FURTO (CP, ART. 155, § 4º).

ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE CONTRADIÇÃO LÓGICA QUE POSSA OBSTAR A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DOS DOIS INSTITUTOS QUANDO PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO FÁTICA. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com



intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. STF. 2ª Turma. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Por fim diante da tentativa, devidamente comprovada nos autos, a pena deve ser diminuída em 1/2, considerando o iter criminis perpetrado pelo acusado que, após unir-se com seus comparsas, escolher a residência, na qual ira entrar, já havia arrombado as portas da residência e estava já pronto para nela ingressar, e somente não consumou o delito, pois ouviu barulho dentro do local e ainda porque sua esposa o chamou. A pena, então, deve ser fixada em 01 ano, 10 meses e 12 dias, e 8 dias-multa.

Do crime de resistência:

O réu é reincidente, consoante verificado a fls. 58.

Além disso, possui outra condenação anterior, (autos nº 0069775-35.2012.8.26.0050), demonstrando que tem personalidade voltada para o crime, assim sendo, como acima apontado não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e assim sendo, a pena base será aumentada em 1/6, chegando-se a 02 meses e 10 dias de detenção.

Na segunda fase, presentes duas agravantes, a reincidência acima apontada, bem como a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, que deve ser reconhecida, pelos motivos e fundamentos acima expostos. Portanto, a pena ser agravada em mais 1/5, perfazendo 02 meses e 24 dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação de pena, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Considerando, ainda, o concurso de crimes, nos moldes previstos no art. 69, "caput", do Código Penal, e as penas devem ser somadas, chegando-se à reprimenda de 01 ano, 07 e 18 dias de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 06 dias-multa.

Por fim, como não há nos autos provas da condição financeira do acusado, os dias-multa serão fixado no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto julgo PROCEDENTE, a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 02 anos, 03 meses e 06 dias de pena privativa de liberdade e 08 dias multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV combinado com o artigo 14, inciso II e art. 329, caput na forma do artigo 69 todos do Código Penal.

Incabível, ao caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão da reincidência em crime doloso, maus antecedentes, sendo nítido que tal substituição não lhe é suficiente.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis aplicadas ao réu, além de sua reincidência.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontestável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: ``O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias'' (RTJ 123/547).

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP.

Nessa conformidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início

da execução da pena" (RT 725/533).

"O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2º, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido" (STJ, Resp. 84669/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 14.4.97).

"embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, Dje, 12/02/2021).

Não poderá apelar desta em liberdade, pois o acusado já se encontra custodiado em razão do flagrante que foi convertida em prisão preventiva e um dos efeitos da sentença condenatória é justamente conservar preso aquele que já se encontra custodiado, não sendo recomendável que seja agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois permanecem intactos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, que deve ser mantida notadamente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a decisão que determinou sua prisão preventiva.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD e comunique-se a vítima consoante disposição legal.

Custas na forma da lei. Custas na forma da lei. Deixo de isentar o réu do pagamento da referida taxa, já que não compete a este juízo esta decisão, ainda mais porque, não há os autos qualquer prova da condição econômica do réu, consoante entendimento consolidado como se demonstra na Apelação Criminal nº 1504000-37.2018.8.26.0228, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo)

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA